

1525153-24.2021.8.26.0228

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carlos Eduardo Lora Franco

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/01/2022

... caracterizando assim o crime de tráfico, e sendo impossível a desclassificação do delito.

Railan, ainda, admitiu o tráfico, restando para ele incontroversa a acusação.

Já os demais réus negaram relação com o tráfico ali em curso.

Porém, tais negativas, além de isoladas nos autos, absolutamente não convencem.

Ora, não estivessem envolvidos no tráfico, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

3ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1525153-24.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1525153-24.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

DAVID ANTONIO DA SILVA e outros

Vistos, etc.

Railan Dias dos Santos, David Antonio da Silva e Arnaldo Filho Bezerra da Conceição, qualificado(a)(s) nos autos, foi(ram) denunciado(a)(s) como incurso(a)(s) no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos seguintes termos:

"Consta nos inclusos autos que em 15 de outubro de 2021, às 14h00min, nesta Capital, no Bairro São Rafael, na Rua Bom Pastor, altura do número 31, RAILAN DIAS DOS SANTOS, qualificado à fl. 9, DAVID ANTONIO DA SILVA, qualificado à fl. 7, e ARNALDO FILHO BEZERRA DA CONCEIÇÃO, qualificado à fl. 8, agindo conjuntamente e com unidade de desígnios, trouxeram com eles, expuseram à venda e venderam drogas (cocaína, lança-perfume e maconha), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O delito foi praticado durante estado de calamidade pública em razão da pandemia de COVID-19 (Decreto Municipal 59.291, de 20 de março de 2020).

Segundo o apurado, policiais militares efetuavam operação em local conhecido pelo tráfico de drogas. Eles avistaram os denunciados e mais uma pessoa. Todos correram ao verem os policiais. O denunciado RAILAN, na fuga, jogou fora uma sacola contendo 101 (cento e uma) porções de cocaína, 51 (cinquenta e uma) porções de maconha e 7 (sete) microtubos de lança-perfume. Após a abordagem, os policiais encontraram com

o denunciado DAVID a quantia de R\$ 233,00 (duzentos e trinta e três reais). Com o denunciado ARNALDO foi encontrado um simulacro de arma de fogo. O quarto indivíduo disse que tinha ido lá comprar drogas.

A quantidade e a variedade de drogas encontradas com RAILAN demonstram a finalidade de tráfico.

DAVID, que estava ao lado de RAILAN, portava o dinheiro oriundo da venda dos entorpecentes. Ouvido na Delegacia, fl. 7, DAVID não soube explicar a origem do dinheiro. ARNALDO fazia a segurança da "biqueira". Ouvido na Delegacia, fl. 8, ele não quis explicar porque estava com o simulacro de arma de fogo.

O auto de exibição e apreensão encontra-se à fl. 20. O laudo de constatação provisória encontra-se às fls. 40/43. O lança-perfume tinha o volume de 63 mililitros. A maconha pesava 161,6 gramas e a cocaína pesava 39,4 gramas. Protesto pela posterior juntada do laudo toxicológico.

Ante o exposto, denuncio RAILAN DIAS DOS SANTOS, DAVID ANTONIO DA SILVA e ARNALDO FILHO BEZERRA DA CONCEIÇÃO como incursos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, c.c. os artigos 29 e 61, inciso II, letra "j" (calamidade pública), do Código Penal. Requeiro o recebimento da presente denúncia, a citação para que os denunciados apresentem defesa prévia, oitiva das testemunhas, abaixo arroladas, interrogatórios e, após o processamento, nos termos dos artigos 54 e seguintes da Lei 11.343/06, a final condenação. "

Determinada a notificação do(a)(s) acusado(a)(s) (fls. 132), em audiência houve resposta e a denúncia foi definitivamente recebida, sendo colhida a prova oral e o(a)(s) ré(u)(s) interrogado(a)(s), tendo as partes se manifestado em debates. Há laudo de exame do entorpecente a fls. 175/177.

É o relatório.

Decido.

A procedência da ação é de rigor, posto que autoria e materialidade estão suficientemente comprovadas.

De fato, os policiais ouvidos informaram que em local próximo a ponto de tráfico avistaram algumas pessoas, sendo que, ao avistá-los, três deles correram, mas acabaram entrando num local sem saída, onde foram detidos, tendo então sido encontrado um simulacro de arma de fogo com Arnaldo, dinheiro com David, e ainda tendo eles, na fuga, visto o réu Railan dispensando uma sacola dentro da qual foram encontrados os entorpecentes apreendidos. Por fim, a pessoa que permaneceu no local, sem fugir, informou que é usuária de drogas, e estava ali para adquirir entorpecentes.

E não há nos autos a indicação de qualquer razão que teriam os policiais para cometerem crime e colocarem suas carreiras em risco, imputando aos réus, a quem sequer conheciam, crime que não tivesse praticado.

Ademais, os próprios réus admitiram em juízo estar na posse, respectivamente, de tais objetos, incluindo os entorpecentes por parte de Railan.

Não há, portanto, qualquer razão para se desmerecer a palavra dos policiais.

Ainda, o laudo pericial atestou a natureza do entorpecente, e as circunstâncias do fato e da prisão dos fatos (especialmente a quantidade e forma de acondicionamento em porções separadas, além da variedade de substâncias) não deixam dúvidas de que se destinavam a fornecimento a terceiros, caracterizando assim o crime de tráfico, e sendo impossível a desclassificação do delito.

Railan, ainda, admitiu o tráfico, restando para ele incontroversa a acusação.

Já os demais réus negaram relação com o tráfico ali em curso.

Porém, tais negativas, além de isoladas nos autos, absolutamente não convencem.

Ora, não estivessem envolvidos no tráfico, não teriam motivo para fugir ao avistarem os policiais, da mesma forma que o quarto indivíduo, usuário, também não fugiu. E, não estivessem os três réus relacionados entre si, não teriam corrido juntos, para o mesmo local, evidenciando o liame entre eles.

Ademais, caracteristicamente, um dos réus (Railan) portava as drogas, e outro (David) dinheiro, justamente em divisão de tarefas que normalmente é vista no tráfico. Também, não é crível que, a par de tudo isso, fosse estar Arnaldo ainda por mera coincidência portando naquele momento e local o simulacro de arma.

Ora, todos estes fatores evidenciam que, apesar das negativas, estavam, sim, os

réus ali juntos atuando no tráfico de entorpecentes, sendo por isso de rigor a condenação dos três.

E, certa a condenação pelo artigo 33 da Lei nº 11.343/06, passo a dosar a pena. Na fase do artigo 59 do Código Penal, e atento ao disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/06, tenho que é necessária a fixação da pena base acima do piso legal.

O que indica a maior gravidade do delito, e recomenda uma exasperação da pena, é justamente a natureza e quantidade das substâncias apreendidas. Diversas são as substâncias que caracterizam entorpecentes. Contudo, dentro dessas, há algumas que são mais graves, seja por terem maior poder de gerar dependência, seja por serem mais nocivas ao organismo do usuário.

Não há dúvidas de que a cocaína causa dependência com muito mais facilidade que a maconha, assim como gera maiores consequências para o organismo do usuário. Já o crack ou a heroína são ainda muito piores, causando forte vício a partir de poucas utilizações e sendo extremamente nocivos à saúde do usuário.

Embora todas sejam substâncias entorpecentes submetidas à Lei de Tóxicos vigente, não se pode negar que possuem características, seja quanto ao grau de dependência, seja quanto à nocividade, muito diferentes entre si, não podendo ser consideradas de forma absolutamente indistinta na dosimetria da pena correspondente, justamente porque não se pode dar o mesmo tratamento a quem comercializa uma substância extremamente nociva e viciante em relação a outra pessoa que repassa outra substância muito menos danosa, dado que são condutas que atingem de forma diversa os usuários e a própria sociedade.

Assim, em sendo o delito de tráfico de substância mais grave, a pena a ser aplicada, para quem explora o vício e gosto dos usuários, deve ser maior.

E não é demais lembrar que, quanto mais forte a dependência gerada pela substância, mais crimes serão cometidos para sustentar o vício dos dependentes, implicando assim, como dito, numa maior gravidade não só para quem usa o entorpecente, mas sim para toda a sociedade.

Desta forma, tenho aplicado para o tráfico de maconha, droga esta menos nociva, a pena no mínimo legal. Já para o tráfico de cocaína, como no presente caso, aumento esta pena, posto que a destruição nas vidas dos usuários desta substância, explorada pelo traficante, é muito maior.

Mas, além disso, há que se observar a razoável quantidade de entorpecente apreendida, totalizando mais de 150 porções, podendo atingir um considerável número de usuários. Não se pode, portanto, punir este delito da mesma forma que se tivesse sido apreendido com os réus apenas uma dúzia de porções, por exemplo.

Assim, no caso dos autos, aumento a pena base do réu em um ano acima do mínimo na fase do artigo 59 do Código Penal.

Quanto à agravante da prática do delito durante estado de calamidade, respeitado o entendimento do Ministério Público, penso que não é mais aplicável aos fatos praticados a partir de 2021, ao contrário dos delitos cometidos em 2020, após 20 de março.

É que naquela data (20/3/2020) foi editado o Decreto Legislativo Federal nº 6/2020, que reconheceu em âmbito nacional o estado de calamidade pública, com vigência até 31 de dezembro de 2020.

E tal estado de calamidade, no âmbito federal, não foi prorrogado em 2021.

É verdade que há também os Decretos Estadual nº 64.879/20, e Municipal nº 59.291, da mesma data, que, igualmente, reconhece, e declara, o estado de calamidade no estado e no município.

Porém, tais atos, no meu entender, estão vinculados ao decreto federal, e não produzem efeitos, para fins de agravamento de pena, a partir da cessação da vigência daquele.

É verdade que estados e municípios podem declarar estado de calamidade em nível local. Porém, em primeiro lugar, de se observar que o motivo do estado de calamidade, a saber, a pandemia de Covid-19, não é um fenômeno meramente local, e nem nacional, mas sim mundial.

E não faz sentido haver, apenas por isso, estado de calamidade meramente local.

Ademais, e esse é o ponto mais relevante, os decretos do estado e do município não mencionam prazo de validade, e não me parece razoável considerar-se válido um

decreto de calamidade permanente, sem termo certo, ainda que prorrogável.

É justamente por este ponto, não conter prazo de validade, e terem sido editados exatamente no mesmo dia do decreto federal, que entendo que são derivados daquele, e dele dependentes, não produzindo o efeito de manter a situação excepcional de calamidade pública após o fim da vigência da norma nacional.

Por isso, pessoalmente, e admitindo plenamente entendimentos noutro sentido, tenho que não se caracteriza a agravante imputada para fatos praticados a partir de 1º de janeiro de 2021.

Para Arnaldo, reincidente (fls. 63/64, condenação pela 22ª vara criminal), elevo sua pena em um sexto, sendo por isso também descabido o redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Para Railan, confesso, reduzo a pena em um sexto.

E para ele e David, não havendo demonstração de envolvimento anterior no tráfico, entendo possível a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Quanto ao montante da redução, observo que se trata de questão polêmica, já que as circunstâncias que são utilizadas para a concessão ou não do benefício (primariedade, falta de antecedentes e não envolvimento com organizações criminosas nem se dedique a atividades desta natureza) são totalmente objetivas, e não admitem gradação. Ou seja, ou a pessoa atende integralmente aos requisitos, e faz jus ao benefício, ou não atende, e não faz jus. Não servem, portanto, para a escolha do montante de redução a ser aplicado.

Ademais, observo que não me parece que a intenção do legislador tenha sido a de beneficiar aqueles que realmente sejam traficantes “profissionais”, aplicando um pena inferior à que era aplicável na legislação anterior, o que ocorre quando utilizado o redutor em dois terços. Pelo contrário, tudo indica que tal benefício deva ser reservado, especialmente em seus patamares mais elevados, àquelas pessoas, que tenham vida correta, sem nenhuma propensão ao crime, mas que, num momento absolutamente isolado e ocasional, tenham vindo a praticar um delito de tráfico de menor gravidade.

Assim, considerando a natureza do benefício, tenho que se deve considerar para fixação do patamar de redução o grau de eventualidade do delito indicado pelas circunstâncias do fato. Ou seja, se as circunstâncias dos autos indicarem que aquela sem dúvida alguma foi um ação completamente isolada e ocasional, o redutor deve ser aproximar do máximo. Seria o caso, por exemplo, de alguém que tenha atividade profissional definida, e que numa situação completamente específica tenha aceitado, uma única vez, fazer o transporte de entorpecente para outrem, e em quantidade não elevada, sem indicação de ligação com o tráfico organizado. Já, quando se evidencia que aquela não seria uma ação isolada de tráfico, mas sim algo que iria se repetir, ou mesmo atingir mais de uma pessoa, como no caso de alguém surpreendido com diversas porções num local conhecido como ponto de tráfico, então a redução deve ser menor. Pior ainda quando há também a participação de olheiros, ou “contabilidade” de comercialização, que denotem a proximidade com maiores traficantes, hipótese em que a redução deve se aproximar do mínimo, ou sequer ser aplicada, conforme as circunstâncias, se evidenciada a participação em organização criminosa.

No caso dos autos, porém, pesa em desfavor dos réus, em primeiro lugar, que estavam em típica situação de tráfico a varejo, denotando uma ação não absolutamente isolada e ocasional, mas sim que iria se repetir, razão pela qual a redução deve se afastar do piso.

Mas, mais do que isso, o fato de estarem praticando o crime em três pessoas, com evidente divisão de tarefas, e chegando mesmo a envolver “segurança” por pessoa com réplica de arma de fogo, fica evidente uma maior sofisticação na prática do crime, demonstrando maior imersão nele, razão pela qual aplico o redutor em apenas metade, finalizando as penas de David em 3 anos de reclusão, e 300 dias-multa, de Railan em 2 anos e 6 meses de reclusão, e 250 dias-multa, e de Arnaldo em 7 anos de reclusão, e 700 dias-multa.

Para Arnaldo, reincidente, o regime inicial não poderá ser outro que não o fechado.

Para Railan e David, em que pese o montante da pena, ante as circunstâncias negativas indicadas quando do aumento da pena base, e também a sofisticação na

prática do crime com divisão de tarefas mencionada na fixação do redutor, entendo por demais brando o regime inicial aberto, razão pela qual aplico o intermediário como inicial, sendo pela mesma razão descabida a substituição da pena. E, tendo os réus respondido ao feito custodiados, e restando reforçadas por esta sentença as razões que levaram anteriormente a suas custódias cautelares, especialmente observando as penas aplicadas e as circunstâncias desfavoráveis acima indicadas, não há razão para o reconhecimento de situação excepcional que justificasse o direito de apelar em soltos, nos termos do art. 59 da Lei nº 11.343/06.

Isto posto, julgo a presente ação PROCEDENTE, para condenar Railan Dias dos Santos, David Antonio da Silva e Arnaldo Filho Bezerra da Conceição, qualificado(a)(s) nos autos, como incurso(a)(s) no artigo 33, caput, (Arnaldo) e 33, § 4º (Railan e David) da Lei nº 11.343/06, às penas de 7 anos de reclusão em regime inicial fechado e 700 dias-multa, estes no mínimo legal, para Arnaldo, 3 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, e 300 dias-multa, no piso, para David, e 2 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e 250 dias-multa, no piso, para Railan, sendo descabida a substituição das penas.

Os réus não poderão apelar em liberdade, nos termos supra.

Expeçam-se ofícios de recomendação, determinando a colocação de Railan e David no regime da condenação.

Não havendo impugnação ao laudo pericial, inexistindo assim dúvida sobre a natureza da droga e considerando as precárias condições de acondicionamento destas substâncias nas Delegacias de Polícia, determino que caso ainda não tenha sido feito, oficie-se, independente do trânsito em julgado, comunicando a autorização para incineração integral dos entorpecentes apreendidos, incluindo amostras.

Determino, outrossim, o perdimento dos valores apreendidos em favor da União, nos termos da Lei de Tóxicos, a ser comunicado após o trânsito em julgado.

Oficie-se desde já comunicando a autorização para destruição dos demais objetos sem valor econômico apreendidos (simulacro de pistola).

Custas pelo(a)(s) condenado(a)(s), na forma do artigo 4º, § 9º, a, da Lei nº 11.608/03, observando que a gratuidade decorrente da atuação da Defensoria Pública não exclui a responsabilidade final, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º da Lei nº 13.105/15, que modificou a Lei nº 1.060/50, e que só se efetiva, por ser cobrada como dívida de valor (execução fiscal) sobre o patrimônio do devedor, não implicando em nenhum risco à sua subsistência.

P.R.I.C.

São Paulo, 18 de janeiro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carlos Eduardo Lora Franco

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA